

HOOFDSTUK 4

Verrekenprijsmethoden

4.1 Inleiding

De keuze van een verrekenprijsmethode is een belangrijke stap op zoek naar de arm's-length-prijs. Deze keuze wordt nagenoeg geheel ingegeven door de functionele analyse. De methode is daarbij een middel en geen doel op zich bij het vinden van een zakelijke prijs. Zoals in hoofdstuk 3 reeds is besproken, gaat het bij het zoeken naar de juiste verrekenprijs om een dynamisch proces waarbij eerder gemaakte keuzen later kunnen worden herzien. Uiteindelijk dient beoordeeld te worden of de prijs of beloning als arm's length kan worden aangemerkt.

In de keuze voor een methodiek om te komen tot een arm's-lengthverrekenprijs maken de OESO-richtlijnen onderscheid tussen de zogenaamde traditionele transactiemethoden en de transactionele winstmethoden, die in de hiernavolgende paragrafen zullen worden besproken.¹

De traditionele transactiemethoden zijn de volgende:

- de comparable-uncontrolled-pricemethode (CUP);
- de resale-pricemethode;
- de cost-plusmethode.

De transactionele winstmethoden zijn:

- de profit-splitmethode;
- de transactionele nettomargemethode (TNMM).
 - Bij de CUP wordt vergeleken op het niveau van de prijs van de goederen en de diensten, bij de resale-price/cost-plus op het niveau van de brutomarge die behaald wordt met de transacties en bij de TNMM/profit-split op het niveau van de nettomarge in relatie tot de uitgeoefende activiteiten.

¹ Par. 2.1 OESO-richtlijnen.

- In het volgende schema wordt aangegeven op welk niveau van de verlies- en winstrekening de methode betrekking heeft:

<u>Omzet</u>	<u>100</u>	<u>CUP</u>
<u>Inkoopwaarde</u>	<u>80</u>	
<u>Brutomarge</u>	<u>20</u>	<u>Resale-price/cost-plus</u>
<u>Operationele kosten</u>	<u>10</u>	
<u>Nettomarge</u>	<u>10</u>	<u>TNMM/profit-split</u>
<u>Buitengewone baten/lasten en rente</u>	<u>5</u>	
	<u>5</u>	

- Vóór de wijziging van de OESO-richtlijnen in 2010 werden de traditionele transactiemethoden als 'preferred methods' aangemerkt. Daarbij had de CUP-methode de voorkeur als de toepassing ervan mogelijk was. Daarmee werd beoogd bij de vergelijking zo dicht mogelijk bij de geanalyseerde transacties te blijven. De transactionele winstmethoden werden 'methods of last resort' genoemd. Daarmee werd beoogd dat de winstmethoden slechts in uiterste noodzaak gebruikt zouden worden.
- In de praktijk bleek die uiterste noodzaak eerder regel dan uitzondering te zijn vanwege het ontbreken van voldoende goed vergelijkingsmateriaal bij de andere methoden. Daarom heeft de OESO ervoor gekozen deze hiërarchie bij het gebruik van methoden in 2010 te laten vallen. Tevens wordt er meer toelichting gegeven bij het gebruik van de winstmethoden. Het is echter niet zo dat de verrekenprijsanalyse nu kan geschieden door een ondernemingsvergelijking op het niveau van de nettowinst, waarbij de beoordeling van de transacties als zodanig wordt losgelaten. Nog steeds is het van het grootste belang om bij de analyse zo veel als mogelijk de zakelijkheid van de individuele transacties in ogenschouw te nemen. Juist in deze analyse komt het karakter van de functionaliteit van de partijen die de transactie aangaan naar voren. In geen geval mag het automatisme ontstaan dat bij bedrijven die meer of minder dan een gemiddeld nettowinstpercentage realiseren een verrekenprijsdiscussie ontstaat.

Bij de keuze van de verrekenprijsmethode dient rekening gehouden te worden met:²

- de relatieve sterkte en zwakte van de verschillende methoden;
- de aard van de geanalyseerde transactie, rekening houdend met de functionele analyse;
- de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens van derden;
- de mate van vergelijkbaarheid tussen de gelieerde en ongelieerde transacties;
- de mate waarin aanpassingen mogelijk zijn.

De hiërarchie van de methoden in de richtlijnen is nog niet helemaal verdwenen. Als de toepassing van twee methoden op een even betrouwbare wijze kan plaatsvinden dient er nog steeds gekozen te worden op basis van de voormalige rangorde.³

² Par. 2.2 OESO-richtlijnen.

³ Par. 2.3 OESO-richtlijnen.

Tevens kunnen ondernemingen iedere andere niet in de OESO-richtlijnen genoemde methode toepassen, mits deze methode ertoe leidt dat de in gelieerde transacties gehanteerde verrekenprijzen voldoen aan het arm's-lengthbeginsel.⁴

In de OESO-richtlijnen worden ten aanzien van het gebruik van de methoden nog enkele algemene opmerkingen gemaakt:

- a) geen enkele methode is geschikt voor iedere situatie;
- b) het is niet nodig aan te tonen dat een bepaalde niet-gebruikte methode ongeschikt is;
- c) het is niet vereist meer dan één methode toe te passen ter onderbouwing van de zakelijkheid van de prijzen;
- d) een belastingplichtige moet bereid zijn de schriftelijke onderbouwing met betrekking tot de totstandkoming van zijn verrekenprijzen te bewaren en te overleggen;
- e) belastingdiensten moeten terughoudend zijn bij het aanbrengen van kleine of marginale correcties.

In het Nederlandse beleid is het volgende bepaald ten aanzien van het gebruik van methoden:⁵

"De Nederlandse belastingdienst dient haar onderzoek van de verrekenprijzen conform paragraaf 4.9 van de OESO-richtlijnen altijd te starten vanuit het perspectief van de door belastingplichtige gehanteerde methode ten tijde van de transactie. Hieruit volgt dat belastingplichtige in principe vrij is in de keuze van een verrekenprijsmethode, mits de gekozen methode leidt tot een arm's length uitkomst voor de specifieke transactie. Voor bepaalde situaties zal de ene methode echter tot betere uitkomsten leiden dan een andere. Hoewel van belastingplichtige kan worden verwacht dat hij bij zijn keuze van een verrekenprijsmethode rekening houdt met de betrouwbaarheid van de methode voor de betreffende situatie, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat belastingplichtige alle methoden beoordeelt en vervolgens onderbouwt waarom de door hem gekozen methode onder de gegeven omstandigheden tot de beste uitkomst leidt (de zogenaamde 'best method rule'). In sommige situaties kan ook een combinatie van methoden worden gebruikt. Belastingplichtige is echter niet verplicht om meerdere methoden te hanteren. Wel zal belastingplichtige zijn keuze aannemelijk moeten maken."

De Nederlandse belastingdienst zal zijn onderzoek naar de verrekenprijzen starten vanuit de door de belastingplichtige gehanteerde methode. Men zal dus niet zonder nadere onderbouwing een door belastingplichtige gehanteerde methode kunnen vervangen door een andere verrekenprijsmethode. Indien daar aanleiding voor is kan een gebruikte methode wel ter discussie gesteld worden. Dat kan zijn als de methode niet past bij de functies van de belastingplichtige. Indien het verschil in uitkomst tussen beide methoden marginaal is, dient de belastingdienst af te zien van een correctie.

4.2 De comparable-uncontrolled-pricemethode (CUP)

De CUP-methode vergelijkt de prijs die wordt berekend voor goederen of diensten die worden overgedragen in een concerntransactie, met de prijs van goederen of diensten die worden overgedragen in een vergelijkbare vrijemarkttransactie onder vergelijkbare

⁴ Par. 2.9 OESO-richtlijnen.

⁵ Besluit van 14 november 2013, IFZ 2013/184M, BNB 2014/132, par. 3.1.

omstandigheden.^{6,7}Een verschil tussen deze twee prijzen kan erop wijzen dat de prijs van de concerntransactie niet in overeenstemming is met het arm's-lengthbeginsel. De CUP-methode is de methode die het beste aansluit bij de feitelijk aangegane transacties.

De CUP-methode is de meest betrouwbare methode vanwege de directe vergelijking van de prijzen en omdat een verschil in prijzen veelal direct herleid kan worden tot een verschil in de voorwaarden tussen de gelieerde en de ongelieerde transactie.⁸ De CUP-methode kent een tweezijdig perspectief waarbij bij de analyse van de gehanteerde voorwaarden zowel de positie van de afnemer als de leverancier in de beschouwing wordt betrokken.

Er zijn twee soorten CUP's, de interne CUP en de externe CUP. Er is sprake van een interne CUP indien door de onderneming naast de transactie met de gelieerde onderneming ook vergelijkbare transacties worden verricht met ongelieerden. Er is sprake van een externe CUP indien sprake is van vergelijkbare transacties onder vergelijkbare omstandigheden tussen twee andere ongelieerde partijen. Externe CUP's zijn relatief zeldzaam in de praktijk. In een aantal situaties kan de CUP op indirecte wijze worden gevonden aan de hand van noteringen op (commodity)beurzen. Voor goederen die aan beurzen zijn genoteerd (zoals goud, olie, katoen, koffie, cacao, aardappelen) kan de notering een waardevolle informatiebron zijn bij het beoordelen van verrekenprijzen. Uiteraard moeten de transacties als zodanig wel functioneel vergelijkbaar zijn, dan wel door aanpassingen vergelijkbaar kunnen worden gemaakt.

In sommige landen wordt wel gebruikgemaakt van de zogenaamde 'sixth method' die bij de levering van bepaalde grondstoffen uitgaat van de genoteerde prijzen zonder te kijken naar de specifieke omstandigheden waaronder deze goederen geleverd worden. Daarbij valt te denken aan onder andere de omvang van het volume of de te maken transportkosten die een invloed kunnen hebben op de prijs. Hoewel deze methode zich kenmerkt door zijn eenvoud is het de vraag of de uitkomst altijd arm's length is. Deze benadering heeft wel kenmerken van de CUP. Het verschil lijkt hem vooral te zitten in het ontbreken van adequate 'comparability adjustments'.

In het BEPS-project is, mede door aandrang van landen die deze methode gebruiken, aandacht geweest voor de hantering van de 'sixth method'. Het gebruik van genoteerde prijzen wordt vanaf 2016 in de OESO-richtlijnen aanbevolen als CUP indien er voldoende accurate 'comparability adjustments' kunnen worden aangebracht zodat voldoende aandacht gegeven kan worden aan de verschillen tussen de transacties waarvoor openbare prijsnoteringen bekend zijn en de transacties zoals die tussen de gelieerde partijen plaatsvinden.⁹

6 Par. 2.13 OESO-richtlijnen.

7 Soms wordt in het kader van de CUP-methode een royaltypercentage vergeleken met een royaltypercentage dat in een ongelieerde situatie tot stand is gekomen. Los van de vraag of in rekening gebrachte royalties met betrekking tot (unieke) intangibles wel vergeleken kunnen worden met royalties van andere (unieke) intangibles, gaat het hier mijns inziens niet om een CUP. Het royaltypercentage is namelijk geen absolute prijs van een bepaald goed maar afhankelijk van een andere variabele. Die variabele is in veel gevallen de gerealiseerde omzet van de royaltybetalende partij.

8 Par. 2.14 OESO-richtlijnen.

9 Par. 2.16 c OESO-richtlijnen

Daarbij werd wel geconstateerd dat gelieerde partijen met deze prijzen kunnen manipuleren door de voor hen meest gunstige prijs te kiezen in de periode waarin de handelingen met betrekking tot de betreffende intercompany transactie plaatsvinden. Onder specifieke omstandigheden, met name als de prijs gebaseerd is op een (dag)notering die niet logisch voortvloeit uit de feiten en omstandigheden waaronder de transactie heeft plaatsgevonden, krijgen belastingdiensten de mogelijkheid om uit te gaan van de prijs die openbaar bekend was op het moment van de vervoersdatum.¹⁰

Om te bepalen of de concerntransactie en de markttransactie vergelijkbaar zijn, moet in ieder geval een vergelijkbaarheidsanalyse uitgevoerd worden waarbij naast de kenmerken van de goederen en diensten ook de andere vergelijkbaarheidsfactoren aan de orde komen. Zo zijn mede van belang de contractuele voorwaarden, de marktomstandigheden (bijvoorbeeld groothandels- of consumentenmarkt), de geografische locatie van de markt, de ondernemingsstrategie, de transactiedatum en de relatie met specifieke intangibles.

Er is sprake van vergelijkbaarheid als aan één van de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. geen van de (eventuele) verschillen tussen de transacties die worden vergeleken kan materiële invloed hebben op de prijs;
2. er zijn redelijk nauwkeurige correcties mogelijk om de materiële effecten van dergelijke verschillen op te heffen.¹¹

Het is vaak niet eenvoudig om de aanpassingen te bepalen. De betrouwbaarheid van de CUP-methode wordt met name beïnvloed door de mate van nauwkeurigheid waarmee aanpassingen kunnen worden aangebracht om de vergelijkbaarheid mogelijk te maken. Het feit dat het moeilijk is redelijk nauwkeurige aanpassingen aan te brengen, is volgens de OESO-richtlijnen geen reden de toepassing van de CUP-methode bij voorbaat uit te sluiten. Ook in de richtlijnen van 2010 blijft de OESO de CUP als methode sterk propageren, ondanks het feit dat deze methode in de praktijk spaarzaam wordt toegepast.

Voorbeeld met betrekking tot verschillen in leveringsvoorwaarden

De in Nederland gevestigde X bv levert goederen aan gelieerde en ongelieerde afnemers. De voorwaarden van de transacties zijn identiek, met uitzondering van de leveringsvoorwaarden. Aan de gelieerde afnemer wordt franco huis geleverd tegen een prijs van € 14 per stuk. Aan de derde wordt free-on-board (f.o.b.) geleverd tegen een prijs van € 12 per stuk. De additionele transportkosten voor de franco aan huis levering bedragen € 3. De aangepaste CUP bedraagt € 15, namelijk de derdenprijs van € 12 plus de additionele transportkosten.¹² De aan de gelieerde afnemer in rekening gebrachte prijs van € 14 per stuk is niet at arm's length en kan mogelijk gecorrigeerd worden tot € 15.

4.3 De resale-pricemethode

De resale-pricemethode gaat uit van de prijs waartegen een product wordt doorverkocht aan een onafhankelijke onderneming en analyseert de daarbij te realiseren brutowinst. De verkoopprijs aan de partij buiten het concern is feitelijk het startpunt van de analyse om te bepalen wat de zakelijke prijs dient te zijn van de inkoop bij een gelieerde

¹⁰ Par. 2.16 e OESO-richtlijnen

¹¹ Par. 2.14 OESO-richtlijnen.

¹² Hierbij wordt geabstraheerd van een eventuele winst op de transportfunctie.

vennootschap. De prijs aan de ongelieerde partij is per definitie arm's length en wordt vervolgens verminderd met een passende brutowinst, waaruit de verkoper zal trachten zijn verkoop- en andere exploitatiekosten goed te maken en met het oog op de vervulde functies (met inachtneming van de gebruikte activa en de gelopen risico's) een passende winst te behalen. De resale-price minus de passende brutowinst vormt de verrekenprijs tussen de verkoper en de aan hem gelieerde onderneming. Dit kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld:

Voorbeeld

Een distributeur koopt zijn voor de omzet bestemde goederen in van een met hem gelieerde leverancier. Hij verkoopt de goederen door aan ongelieerden voor een prijs van € 50 per stuk (de resale-price of RP). De inkoopprijs van de goederen bedraagt € 45 per stuk. De vraag is of dit een arm's-lengthprijs is. Uit onderzoek is gebleken dat de door vergelijkbare onafhankelijke distributeurs behaalde resale-pricemarge (RPM) 20% is. De arm's-lengthverrekenprijs (TP) voor de goederen, gekocht van de gelieerde leverancier, kan worden bepaald met behulp van de volgende vergelijking:

$$TP = RP (1 - RPM) = 50 (1 - 0,2) = 40$$

De gehanteerde verrekenprijs van € 45 is derhalve niet arm's length en kan mogelijk gecorrigeerd worden.

In de OESO-richtlijnen worden verschillende toepassingsmogelijkheden van de resale-pricemethode genoemd waarbij het in het algemeen gaat over de verkoopactiviteiten in de laatste schakel van de value-chain van de onderneming. Het betreft de verkoop aan ongelieerde partijen, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat die verkoopprijs zakelijk is en het hier gaat om de analyse van de transactie in de schakel daarvoor.

De resale-pricemethode is in het algemeen beter toepasbaar als:

- a) er weinig tijd verloopt tussen de inkoop en de uiteindelijke verkoop;
- b) het product weinig bewerkingen ondergaat door handelingen van de verkoper;
- c) er weinig waarde wordt toegevoegd door de verkoper.¹³

De hoogte van de te behalen brutowinst is afhankelijk van de uitgeoefende functies met inachtneming van de veronderstelde risico's en de gebruikte activa. De arm's-lengthrange van zakelijke resale-pricemarges dient op basis van een vergelijkbaarheidsanalyse en een zoektocht naar 'comparables' te worden vastgesteld. De uitkomst van deze zoektocht is sterk afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van de betreffende transacties.

Vergelijkbaarheid

Om te bepalen of de brutowinst arm's length is, wordt de in de gelieerde transactie behaalde resale-pricemarge vergeleken met door onafhankelijke derden in vergelijkbare transacties onder vergelijkbare omstandigheden behaalde brutowinstmarge (externe resale-pricemarge) of met de behaalde brutowinstmarge op van onafhankelijke derden ingekochte goederen (interne resale-pricemarge).¹⁴

In de OESO-richtlijnen wordt aangegeven dat in een markteconomie de beloningen voor het vervullen van gelijksoortige functies bij verschillende producten met elkaar

¹³ Par. 2.29 OESO-richtlijnen.

¹⁴ Par. 2.22 OESO-richtlijnen.

gelijk kunnen zijn. Als de beloning voor de vergelijkbare activiteiten (de functie) gelijk is, hoeft de prijs van de producten niet precies dezelfde te zijn. In de OESO-richtlijnen wordt ter illustratie hiervan een voorbeeld gegeven van een distributiebedrijf dat dezelfde functies vervult bij de verkoop van zowel broodroosters als mixers.¹⁵ Hoewel de prijs van de producten niet zal overeenkomen kan de beloning voor de verkoopfunctie (de marge in relatie tot de omzet) voor beide producten toch vergelijkbaar zijn.

Bij de toepassing van de resale-pricemethode speelt productvergelijking een minder belangrijke rol dan bij de CUP-methode en worden met name de uitgeoefende functies met elkaar vergeleken. Volgens de OESO-richtlijnen mag echter niet uit het oog worden verloren dat een grotere vergelijkbaarheid van producten ook bij de resale-pricemethode uiteindelijk wel betere resultaten oplevert en daarom de voorkeur geniet.

Verschillen in functies

Indien de resale-pricemarge wordt afgeleid van de marge die een onafhankelijke ondernemer verdient bij vergelijkbare vrijemarkttransacties, is het nog wel van belang om te kijken of er sprake is van verschillen met betrekking tot de bedrijfsuitoefening. Daarbij kunnen verschillen in operationele kosten wijzen op verschillen in functies en activiteiten, die een effect kunnen hebben op de brutomarge van de onderneming. De richtlijnen bevelen dan ook aan dit soort factoren te analyseren om te bepalen of de transacties daadwerkelijk vergelijkbaar zijn.

Als materiële verschillen in de bedrijfsuitoefening van invloed zijn op de brutowinstmarges moeten er correcties worden aangebracht om deze verschillen op te heffen en de vergelijkbaarheid mogelijk te maken. Dit kan geïllustreerd worden met het volgende voorbeeld.

Voorbeeld

De gelieerde distributeur X bv behaalt een resale-pricemarge van 15% (in relatie tot de omzet). Deze distributeur houdt een voorraad aan van de te verkopen producten en loopt hierover het risico van veroudering. De met deze functie gepaard gaande kosten bedragen gemiddeld 2% van de omzet. Een vergelijkbare onafhankelijke distributeur behaalt een resale-pricemarge van 14% van de omzet. Deze distributeur houdt geen voorraad aan omdat de producten rechtstreeks van de fabriek aan de uiteindelijke afnemer geleverd worden. Het verschil in functies en risico's kan in dit geval worden gecorrigeerd door de resale-pricemarge van de onafhankelijke distributeur te verhogen met de door X bv aan de voorraadfunctie gerelateerde kosten. De vergelijkbaar gemaakte resale-pricemarge van de onafhankelijke distributeur bedraagt dan $14\% + 2\% = 16\%$. Indien de onafhankelijke distributeur ook een vergelijkbare voorraadfunctie als X bv zou vervullen, zou hij immers minimaal de daarmee gepaard gaande kosten terug willen verdienen in zijn brutowinstmarge. Ik voeg daar nog aan toe dat ook nog stilgestaan dient te worden bij de vraag of voor die voorraadfunctie daarnaast nog een passende winstopslag redelijk is. In het bovenstaande is daaraan gemakshalve voorbij gegaan, hoewel het vanuit economische overwegingen zakelijk is om een dergelijke winstopslag wel te veronderstellen. Indien een redelijke winstopslag (gerelateerd aan de kosten) 10% zou zijn zou de zakelijke winstmarge 16,2% bedragen ($16\% + (10\% \cdot 2\%)$).

Indien het verschil in functies niet goed valt te waarderen, kan de ongelieerde onderneming niet als 'comparable' gebruikt worden.

¹⁵ Par. 2.24 OESO-richtlijnen.

Verschillen in de verwerking in de jaarrekening

Indien er verschillen bestaan tussen de wijze waarop kosten worden verwerkt in de verlies- en winstrekening van de gelieerde onderneming en de ongelieerde onderneming, heeft dat ook invloed op de vergelijkbaarheid van de resale-pricemarges. Ook dan zijn aanpassingen op hun plaats.

Voorbeeld

Een gelieerde distributeur X bv behaalt een omzet van € 1000, de inkoopwaarde van de goederen bedraagt € 725 en de operationele kosten € 200. De operationele winst van X bv bedraagt derhalve € 75. X bv verwerkt de verkoopkortingen in de operationele kosten.

Een vergelijkbare onafhankelijke distributeur D behaalt eveneens een omzet van € 1000. De inkoopwaarde van zijn goederen bedraagt € 750, inclusief de bij de inkoopwaarde geboekte verkoopkortingen ten bedrage van € 50. Zijn operationele kosten bedragen € 150. De operationele winst van D bedraagt € 100.

De door X bv behaalde resale-pricemarge bedraagt 27,5% $((1000 - 725) / 1000)$ en de door D behaalde resale-pricemarge bedraagt 25% $((1000 - 750) / 1000)$. Zonder een correctie om het verschil in verwerking van de verkoopkortingen weg te nemen kunnen deze marges niet met elkaar worden vergeleken. De resale-pricemarges kunnen vergelijkbaar worden gemaakt door de verkoopkortingen bij D te 'verplaatsen' van de inkoopwaarde van de goederen naar de operationele kosten. De inkoopwaarde van de goederen van D wordt dan € 700 en zijn resale-pricemarge 30%. Dit is 2,5% hoger dan die van X bv. De fiscus zou hier aanleiding in kunnen zien de verrekenprijzen ter discussie te stellen.

Uit dit voorbeeld blijkt dat het bij de toepassing van de resale-pricemethode van groot belang is hoe bepaalde kosten in de jaarrekening verwerkt worden en dat daar bij de vergelijking rekening mee moet worden gehouden. Als gekozen zou zijn voor de TNMM (waarbij de operationele nettowinst in plaats van de brutowinst vergeleken wordt) zou dit probleem zich niet hebben voorgedaan. De operationele winstmarge (uitgedrukt als percentage van de omzet) van X bv bedraagt 7,5% en die van D 10%. Ook hier is het verschil 2,5% waarbij direct zonder aanpassing zichtbaar is dat het resultaat van X bv mogelijk gecorrigeerd kan worden.

De resale-pricemethode is moeilijker toepasbaar in het geval de verkoper in aanzienlijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling en instandhouding van op het product betrekking hebbende immateriële goederen (bijvoorbeeld handelsmerken en handelsnamen) waarvan de verkoper zelf niet de juridische eigendom bezit.¹⁶ 'Comparables' zijn dan moeilijker te vinden omdat de functie complexer wordt. Indien de verkoper bijdraagt aan de merknaam, zal dat tot uitdrukking moeten komen in de hoogte van de resale-pricemarge. Het is ook denkbaar dat de verkoper separaat extra wordt gecompenseerd voor deze activiteiten, bijvoorbeeld door een kostengerelateerde beloning. Het is daarnaast nog mogelijk dat de verkoper op deze wijze zelf een marketing intangible ontwikkelt. Te denken valt hierbij aan een waardevol klantenbestand. Ook dat zal uiteindelijk in zijn beloning tot uiting moeten komen. In hoofdstuk 6 over intangibles ga ik hier nader op in.

Het is overigens noodzakelijk dat de berekening van de brutowinst niet wordt gerelateerd aan omzet die tot stand is gekomen op basis van gelieerde transacties. De berekening van het brutowinstpercentage op basis van omzet die in rekening gebracht is aan gelieerde vennootschappen zal geen goede basis vormen voor een vergelijkbaarheidsanalyse. Dit geldt overigens voor alle methoden die een relatie leggen tussen de bruto- of nettowinst en de omzet, kosten of activa en in het vervolg van dit hoofdstuk nog worden besproken. De betreffende omzet, kosten of activa mogen niet 'vervuild' kunnen zijn als gevolg van het

¹⁶ Par. 2.31 en 2.32 OESO-richtlijnen.

feit dat ze in gelieerde transacties tot stand zijn gekomen.¹⁷ We weten immers niet of de basis (kosten, activa of omzet) van de berekening wel bestaat uit arm's-lengthprijzen. De grondslag voor de berekening van de winst moet op zich niet ter discussie gesteld kunnen worden vanwege onzekerheid over het arm's-lengthkarakter ervan.

4.4 De cost-plusmethode

De cost-plusmethode gaat uit van de kosten die de leverancier van goederen of de dienstverlener heeft gemaakt. Aan deze kosten wordt vervolgens een passende winstopslag toegevoegd, teneinde gelet op de vervulde functies, de gebruikte activa en de daarbij veronderstelde risico's, een winst te kunnen realiseren. De prijs die tot stand komt na toevoeging van de winstopslag kan worden beschouwd als de arm's-lengthprijs van de concerntransactie.¹⁸

Voorbeeld

Een loonproducent X produceert halffabricaten ten behoeve van gelieerde productieondernemingen. Aangenomen kan worden dat, gelet op de uitgeoefende functies, de gelopen risico's en de gebruikte activa, de cost-plusmethode de meest geschikte verrekenprijsmethode is. De directe en indirecte productiekosten (TC) bedragen € 15 per stuk. Vergelijkbare onafhankelijke ondernemingen verdienen een brutowinstmarge (GM) van 15% op hun directe en indirecte productiekosten. De verrekenprijs (TP) kan als volgt worden bepaald:

$$TP = TC * (1 + GM) = 15 * 1,15 = € 17,25$$

Indien X minder dan € 17,25 in rekening brengt kan er mogelijk een correctie worden aangebracht.

Deze methode, waarbij de beloning wordt berekend als een percentage van de kosten, is bruikbaar wanneer sprake is van de productie van goederen of de levering van diensten. De hoogte van de winstopslag is afhankelijk van de uitgeoefende functies met inachtneming van de veronderstelde risico's en de gebruikte activa. De arm's-lengthrange van zakelijke winstopslagen dient op basis van een vergelijkbaarheidsanalyse en een zoektocht naar 'comparables' te worden vastgesteld. In de Nederlandse jurisprudentie is de hoogte van de winstopslag een aantal malen aan de orde geweest.¹⁹ In zijn algemeenheid valt daar weinig over te zeggen. De hoogte is sterk afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van een casus. Maar voor de bepaling van de winstopslag zijn zeker ook de aard en omvang van de gemaakte kosten die deel uitmaken van de grondslag van groot belang.

¹⁷ Par. 2.88 OESO-richtlijnen.

¹⁸ Par. 2.39 OESO-richtlijnen.

¹⁹ Zie o.a. Hof 's-Gravenhage 30 juni 1966, nr. 101/1965 M I, *BNB* 1966/250 voor de beloning van administratieve diensten; HR 28 november 1984, nr. 2577 (concl. A-G Van Soest), *BNB* 1989/114, m.nt. Den Boer, inzake de beloning van de bankgirocentrale; HR 25 november 1992, nr. 27 519 (concl. A-G Verburg), *BNB* 1993/41, m.nt. Bartel, inzake een inkoopkantoor van kleding; HR 8 november 1995, nr. 30 458, *BNB* 1996/64, m.nt. Daniels, inzake de beloning van een distributeur; HR 11 oktober 2000, nr. 35 246 (concl. A-G Van Kalmthout), *BNB* 2001/142, m.nt. Aardema; V-N 2001/47.9; *FED* 2001/134, inzake loonproductie en Hof Arnhem 24 april 2003, MK I, nr. 2001/00047, V-N 2003/29.3.2 inzake de beloning voor een inkoopkantoor van blik.

Vergelijkbaarheid

In de OESO-richtlijnen wordt erop gewezen dat de vergelijkbaarheidsanalyse met betrekking tot de cost-plusmethode in grote mate overeenstemt met de vergelijkbaarheidsanalyse met betrekking tot de resale-pricemethode.²⁰ Ook hier gelden dus de reeds eerder gemaakte opmerkingen met betrekking tot functie- en verslaggevingsverschillen.

Het is van groot belang dat in kaart gebracht wordt wat de verschillen zijn tussen de gelieerde en ongelieerde transacties. Ten behoeve van de vergelijkbaarheidsanalyse is het daarom noodzakelijk aandacht te besteden aan de verschillen in aard en omvang van de kosten die verband houden met de door de partijen vervulde functies. Het gaat hierbij om zowel de exploitatiekosten als de overige kosten. Dit zijn kosten die doorgaans niet in de grondslag voor de winstberekening zijn opgenomen omdat daarbij slechts wordt uitgegaan van de directe en indirecte kosten van de activiteit. De verschillen kunnen duiden op het volgende:

1. de kosten kunnen een verschil in functies weerspiegelen;
2. de kosten kunnen zijn opgeroepen door additionele functies, die mogelijk afzonderlijk beloond moeten worden;
3. de kosten van de partijen die worden vergeleken, weerspiegelen de efficiëntie of inefficiëntie van de bedrijfsvoering van de onderneming. Dit geldt mogelijk voor managementkosten, algemene en administratieve kosten. In dat geval behoeft de prijs niet gecorrigeerd te worden omdat dergelijke oorzaken in principe geen effect hebben op de arm's-lengthprijs van de individuele transactie.²¹

Gelet op het bovenstaande zijn een toll manufacturer en een contract manufacturer niet goed met elkaar vergelijkbaar. De kostengrondslag is verschillend omdat de toll manufacturer doorgaans geen eigenaar wordt van de grondstoffen en de kosten van de grondstoffen daarom geen deel uitmaken van zijn directe kosten. De gelopen risico's zijn ook verschillend. Omdat de functies, de kostengrondslag en de te verdienen beloning (door het hebben van een afwijkend functie- en risicoprofiel) van elkaar verschillen is mijns inziens het vergelijken van een opslag van een contract manufacturer met de opslag van een toll manufacturer hetzelfde als het vergelijken van appels met peren.

Omvang van de kostengrondslag

In de OESO-richtlijnen wordt een driedeling gemaakt van de verschillende kostensoorten:²²

1. directe productiekosten van een product of dienst, zoals de kosten van grondstoffen;
2. indirecte productiekosten die, hoewel ze nauw verband houden met het productieproces, aan meerdere producten of diensten gealloceerd kunnen worden (bijvoorbeeld de afschrijvingskosten van de machines);
3. de exploitatie- of operationele kosten van de onderneming (zoals managementkosten, algemene en administratieve kosten).

Volgens de OESO-richtlijnen geldt in het algemeen dat bij de toepassing van de cost-plus-methode een winstopslag zal worden gehanteerd die is berekend op basis van het totaal

²⁰ Par. 2.41 OESO-richtlijnen.

²¹ Het is aanbevelenswaardig om uit te gaan van de gebudgetteerde kosten. Deze zullen echter van de gevonden 'comparables' doorgaans niet beschikbaar zijn in het publieke domein.

²² Par. 2.47 OESO-richtlijnen.

van de directe en indirecte productiekosten.²³ Bij een cost-plusmethode die betrekking heeft op andere activiteiten, zoals diensten, geldt eenzelfde benadering.

Het bepalen van de kosten

In de praktijk blijkt de bepaling van de omvang van de kosten nogal eens een probleem. De OESO-richtlijnen bevelen in het algemeen aan bij het bepalen van de grondslag de historische kostprijs in aanmerking te nemen.²⁴ Maar tevens wordt gesteld dat in sommige gevallen het gebruik van de vervangingskosten of marginale kosten tot een betere bepaling van de arm's-lengthprijs zal leiden.

Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt lijkt het logisch om rekening te houden met de vervangingskosten. De bedrijfseconomie leert nu eenmaal dat een onderneming haar eigen vermogen in stand zal willen houden. De winstgevendheid dient voldoende te zijn om tijdig vervangingsinvesteringen te doen. Als de onderneming in haar prijsstelling onvoldoende rekening houdt met de prijzen van aan te schaffen bedrijfsmiddelen, zal de continuïteit in gevaar komen.

In de OESO-richtlijnen²⁵ wordt aangegeven dat in sommige gevallen er een goede zakelijke reden kan zijn om uitsluitend uit te gaan van de variabele of marginale kosten bij de bepaling van de grondslag, indien de transacties de afzet van marginale productie betreffen.²⁶ Volgens de OESO-richtlijnen is dit verdedigbaar als de goederen niet tegen een hogere prijs kunnen worden verkocht op de betreffende markt.

Geanalyseerd dient dan te worden of ongelieerde partijen ook een dergelijke handelswijze zouden hebben gevolgd. Het is overigens de vraag in hoeverre voor een partij die beloond wordt op basis van een cost-plusmethode, het verliesgevend opereren met betrekking tot bepaalde transacties zakelijk is. Deze methode wordt namelijk doorgaans gebruikt voor het bepalen van een beloning voor minder complexe diensten of activiteiten met beperkte risico's. Het bewust niet maken van winsten op bepaalde transacties, zonder specifieke compensatie, lijkt voor een routinematige functie met een cost-plusbeloning niet zo voor de hand te liggen.

Een probleem om de kostengrondslag te berekenen doet zich ook nog voor als producten vanuit verschillende bronnen leverbaar zijn tegen zeer uiteenlopende prijzen. In de OESO-richtlijnen wordt voor dat geval opgemerkt dat partijen dan vaak besluiten om hun grondslag op een gestandaardiseerde wijze te berekenen.²⁷ Dit wordt in de bedrijfseconomische theorie wel aangeduid als het bepalen van de standaardkostprijs.

Grondstoffen als onderdeel van de grondslag

Indien de productie van goederen centraal staat, zullen de grondstofkosten een zeer belangrijke component van de totale kosten kunnen uitmaken. Bij een onderzoek naar toepassing van de cost-plusmethode dient dan ook de vraag beantwoord te worden of de grondstofkosten wel of niet deel uitmaken van de grondslag. Startpunt bij de analyse zijn

²³ Par. 2.48 OESO-richtlijnen.

²⁴ Par. 2.49 OESO-richtlijnen.

²⁵ Par. 2.51 OESO-richtlijnen.

²⁶ Zie ook: Durst, 'Management vs. tax accounting in intercompany transfer pricing', *Tax Management Transfer Pricing Report*, 6 maart 2002, blz. 909-915.

²⁷ Par. 2.52 OESO-richtlijnen.

ook hier de contractuele voorwaarden. Als juridisch op naam van de contract manufacturer wordt geproduceerd, zitten in beginsel de grondstoffen in de grondslag. Hiervan kan worden afgeweken als de feitelijke handelingen afwijken van de contractuele voorwaarden.

Het is daarnaast aanbevelenswaardig om bij een vergelijking inzicht te hebben in de mate waarin de omvang van de kosten van de gebruikte grondstoffen bij een productieproces iets zegt over de waardetoevoeging van de producent. Zo zal de diamantslijper die zelf de dure grondstof inkoopt, met een lagere procentuele winstonslag genoegen nemen dan de bakker die het goedkope meel als grondstof gebruikt. Dit zijn aspecten die bij een vergelijkbaarheidsanalyse aandacht verdienen.

Als de grondstoffen geen deel uitmaken van de grondslag, zoals bij toll manufacturers, is het mogelijk dat de te verwachten absolute beloning voor de uitgeoefende functie lager is, omdat er minder activiteiten worden uitgeoefend en/of minder risico's worden gelopen. Waarschijnlijk zal de opslag procentueel gezien hoger dienen te zijn om tot een passende beloning te komen voor de uitgeoefende functies, omdat de grondslag door het ontbreken van grondstoffen aanzienlijk lager is.

Gebudgetteerde of werkelijke kosten

Een ondernemer zal in het algemeen zijn prijzen bepalen voordat hij de goederen of diensten levert. Daarom moet in beginsel worden uitgegaan van de gebudgetteerde kosten. Valt het uiteindelijke resultaat tegen door bijvoorbeeld inefficiëntie of economische ontwikkelingen, dan is dit niet een reden om de prijzen aan te passen. In het Nederlandse verrekenprijsbeleid wordt over dit punt het volgende opgemerkt:²⁸

“Over het algemeen zullen prijzen vooraf worden vastgesteld op basis van de gebudgetteerde kosten. Indien de daadwerkelijke uitgaven die samenhangen met de transacties hoger uitvallen dan deze gebudgetteerde kosten, is het afhankelijk van de oorzaak of dit verschil zal leiden tot een prijsaanpassing. In het algemeen kan ervan uit worden gegaan dat hogere uitgaven als gevolg van inefficiëntie voor rekening van de contractpartij komen die de prestaties verricht. Dit is immers de contractpartij die deze uitgaven kan beïnvloeden. Een onafhankelijke afnemer zal in deze situatie een prijsaanpassing niet accepteren. Voorwaarde voor een juiste vaststelling van de verrekenprijzen op basis van budgetten is dat deze budgetten op een bedrijfseconomisch juiste wijze worden vastgesteld.”

Het zal duidelijk zijn dat bij de bepaling van de verrekenprijzen op basis van gebudgetteerde kosten de ondernemer deze vaststelt door een systematiek van ‘price-setting’. De op dat moment beschikbare vergelijkbare cijfers van ongelieerde transacties worden gebruikt om de te hanteren prijzen te bepalen. Bij een toetssysteem gebaseerd op ‘price-evaluating’ vindt de arm’s-lengthtest achteraf plaats en zullen doorgaans de werkelijke kosten geanalyseerd worden. Dit kan dan doorgaans gebeuren met behulp van recentere informatie over ongelieerde transacties.

Bij een cost-plusbeloning die op basis van de werkelijk gemaakte kosten na afloop van het boekjaar wordt vastgesteld, doet zich het wonderlijke fenomeen voor dat de onderneming ook met betrekking tot de inefficiënte kosten een winst realiseert. Dat lijkt onzakelijk omdat dan in het systeem geen prikkel meer aanwezig is om zo efficiënt mogelijk met zo min mogelijk kosten het gewenste resultaat te bereiken. Dat is op zich ook de reden dat er een voorkeur bestaat om de beloning te baseren op basis van de gebudgetteerde

²⁸ Besluit van 14 november 2013, IFZ 2013/184M, BNB 2014/132, par. 3.2.

kosten. Het is immers vanuit bedrijfseconomisch oogpunt logisch dat efficiencyresultaten voor rekening komen van de partij die deze resultaten vanuit haar functie veroorzaakt.

Buiten aanmerking laten van kosten bij het bepalen van de grondslag

In de grondslag worden de kosten opgenomen die behoren tot de kosten van degene die het product levert of de dienst verricht. Daarbij worden kosten met een 'verschotkarakter' buiten de grondslag gehouden. Dit zijn kosten die in eerste instantie betaald worden door de uitvoerende contractpartij maar in het algemeen afzonderlijk in rekening gebracht kunnen worden aan de opdrachtgever. Hierbij valt te denken aan kosten als leges, griffiekosten en specifieke reis- en/of verblijfkosten. Deze kosten kunnen buiten de grondslag voor het bepalen van de winstopslag blijven, aangezien de uitvoerende contractpartij zelf met deze kosten geen waarde toevoegt.

De kosten van financiering van de activiteiten behoren ook niet tot de grondslag. Deze kosten dienen te worden terugverdiend uit de operationele winst en hebben dus indirect wel effect op de omvang van de te behalen winstmarge.

Samenhang met de TNMM

Daar waar bij de hiervoor omschreven cost-plusmethode op brutowinstniveau de winstopslag wordt berekend op basis van de directe en indirecte kosten van de betreffende activiteit, zal bij de hierna nog te bespreken TNMM met de verhouding operationele winst/kosten als 'profit-levelindicator' de winst tevens gerelateerd worden aan de operationele kosten. De TNMM is daarom te omschrijven als een nettowinstmethode.

Overigens wordt dit scherpe onderscheid in de OESO-richtlijnen wel gerelativeerd door erop te wijzen dat het moeilijk is om de drie genoemde categorieën kosten (direct, indirect, operationeel) precies af te bakenen vanwege de verslaggevingsverschillen die in de praktijk in de verschillende landen bestaan.²⁹ Daarnaast zijn er ook verschillen van mening in het vakgebied van 'cost-accounting' te bespeuren over hoe bepaalde kosten geclassificeerd dienen te worden.

Omdat het onderscheid tussen de kostensoorten vaak zo moeilijk is te maken, wordt in de praktijk zeer vaak overgegaan tot de hantering van een cost-plusmethode op netto-winstniveau (TNMM) waarbij het classificatieverschil minder relevant is.

Veel van de dilemma's en opmerkingen die in deze paragraaf bij de cost-plusmethode zijn gemaakt zijn overigens eveneens van toepassing op de TNMM met de verhouding operationele winst/kosten als 'profit-levelindicator'.

4.5 De transactionele winstmethoden

Binnen de OESO is al jaren sprake van een worsteling met betrekking tot het gebruik van (netto)winstmethoden als basis voor het vaststellen van de verrekenprijzen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het bij het arm's-lengthbeginsel gaat om het vaststellen van prijzen van individuele transacties en niet om de analyse van de (netto)winst. Indien op basis van de (netto) winsten vergeleken wordt gaan gauw heel andere zaken een rol spelen, zoals de vraag of de betreffende onderneming wel op een efficiënte wijze haar bedrijfsgebeuren heeft georganiseerd. Voor zover er dan toch om pragmatische redenen

²⁹ Par. 2.48 OESO-richtlijnen.

bij de vaststelling van de verrekenprijzen gebruik wordt gemaakt van een analyse van de (netto)winst, moet deze altijd weer terug te leiden zijn tot specifieke transacties. Bij de winstmethoden wordt onderscheid gemaakt tussen de 'transactional profitmethod' en de 'transactional profit-splitmethod'. Nu deze methoden in de richtlijnen niet meer, zoals in het verleden, worden aangemerkt als 'methods of last resort' wil dat nog niet zeggen dat ze niet meer onderhevig zijn aan duidelijke richtlijnen die kaders stellen bij het gebruik. De richtlijnen zijn nog steeds doordrenkt van waakzaamheid om te voorkomen dat de verrekenprijsanalyse slechts een vorm van winstvergelijking wordt. Deze methoden mogen niet worden toegepast op een wijze die ertoe leidt dat ondernemingen worden gecorrigeerd alleen omdat hun nettowinst beneden het gemiddelde van vergelijkbare ondernemingen ligt. Dat zou een ongunstige toepassing van het arm's-lengthbeginsel zijn.

Niettegenstaande de bestaande huiver hebben de OESO-landen moeten erkennen dat de nettowinstmethoden in de praktijk meer en meer gebruikt werden om de zakelijkheid van de verrekenprijzen te onderbouwen. De redenen hiervoor hadden vooral betrekking op de beperkte beschikbaarheid van betrouwbare gegevens voor de vergelijking op het niveau van de brutowinsten. De OESO is daarom ruimhartiger geworden met betrekking tot het gebruik van deze methoden. Met behulp van een winstmethode kan de prijs die wordt gehanteerd in specifieke concerntransacties, worden getoetst aan het arm's-lengthbeginsel.

Indien bij de analyse wordt vastgesteld dat de winst van een onderneming als onzakelijk moet worden beschouwd, dient deze analyse tot een herberekening van prijzen van specifieke transacties te leiden. Feitelijk moeten de transacties die de oorzaak zijn van de te lage nettowinst aanwijsbaar zijn. Daarom is het ook noodzakelijk dat de analyse van de winst zo veel mogelijk betrekking heeft op een groep van transacties van soortgelijke producten. Eén van de redenen waarom er bij het gebruik van een nettowinstmethode een relatie gelegd moet kunnen worden naar specifieke transacties, is het gegeven dat correcties in één land moeten kunnen leiden tot een 'corresponding adjustment' in een ander land om op deze wijze de dubbele belastingheffing weg te nemen. Daarom moet bekend zijn welke transacties met welk land de oorzaak zijn van de te lage nettowinst.

4.6 De transactionele nettomargemethode (TNMM)

Bij de transactionele nettomargemethode (TNMM) wordt de operationele winst die een belastingplichtige realiseert bij een concerntransactie in relatie tot een bepaalde basis (kosten, omzet of gebruikte activa) vergeleken met de operationele winst die onafhankelijke derden onder vergelijkbare omstandigheden zouden realiseren.³⁰ De verhouding van de winst ten opzichte van kosten, omzet of gebruikte activa wordt ook wel 'profit-levelindicator' genoemd en wordt als graadmeter bij de vergelijkbaarheidsanalyse gebruikt. De keuze voor de 'profit-levelindicator' (PLI) is afhankelijk van de uitgeoefende functies (inclusief de gelopen risico's en de gebruikte activa). Zo zal het in zijn algemeenheid voor een distributeur voor de hand liggen de winst af te zetten tegen de omzet, terwijl voor een producent de winst wordt afgezet tegen de totale kosten (de directe, indirecte en operationele kosten). Feitelijk is de eerste methode met betrekking tot de distributeur te vergelijken met de

³⁰ Par. 2.58 OESO-richtlijnen.

resale-pricemethode (maar dan op nettoniveau) en de tweede methode met betrekking tot de producent met de cost-plusmethode (eveneens op nettoniveau). Ook andere profit-levelindicators zijn mogelijk. In de OESO-richtlijnen wordt de 'return on operational assets' (de nettowinst uitgedrukt in een percentage van de voor de activiteiten van de onderneming gebruikte activa) genoemd als PLI voor kapitaalintensieve ondernemingen.

In de OESO-richtlijnen wordt erop gewezen dat de operationele marge van een transactie idealiter zou moeten worden vastgesteld aan de hand van de operationele marge die dezelfde belastingplichtige behaalt bij een vergelijkbare vrijemarkttransactie (de zogenoemde interne vergelijking). Als deze interne vergelijking niet mogelijk is, dan kan de operationele marge die zou zijn behaald bij vergelijkbare transacties door een onafhankelijke onderneming, als richtlijn dienen. In het laatste geval is niet alleen een functionele analyse van de gelieerde onderneming nodig, maar ook een functionele analyse van de ongelieerde onderneming. Dit is om te kunnen bepalen of de transacties vergelijkbaar zijn en welke correcties nodig kunnen zijn om tot betrouwbare 'comparables' te komen.

Voorbeeld

Een gelieerde distributeur X verkoopt producten aan onafhankelijke afnemers voor een prijs van € 100 per stuk. Hij koopt de producten in van een gelieerde leverancier voor € 90 per stuk. Het arm's-lengthkarakter van deze prijs staat mogelijk ter discussie.

De toe te rekenen exploitatiekosten bedragen € 8 per stuk. X behaalt een operationele winst van € 2 per product.

De belastingdienst wil de verrekenprijs toetsen aan het arm's-lengthbeginsel. Openbare gegevens over brutowinsten van vergelijkbare distributeurs zijn niet beschikbaar. Gegevens over operationele winsten wel. De belastingdienst besluit daarom het arm's-lengthkarakter van de verrekenprijzen te toetsen met behulp van de TNMM, met de verhouding winst/omzet als 'profit-levelindicator'.

Uit onderzoek door de belastingdienst blijkt dat vergelijkbare distributeurs een operationele marge behalen van 3 tot 4% van de omzet; de mediaan van de waarnemingen is 3,5%. X heeft een operationele marge behaald van 2% (2/100). De verrekenprijzen zijn derhalve niet at arm's length omdat de marge buiten de arm's-lengthrange valt. De operationele winst kan tot 3,5 (3,5% * 100) worden gecorrigeerd. Om te komen tot een passende verrekenprijs dienen daarbij eerst de exploitatiekosten van € 8 opgeteld te worden (die ondergaan geen wijziging), hetgeen een arm's-lengthbrutowinst van € 11,50 oplevert. De omzet van € 100 minus de brutowinst van € 11,50 levert de arm's-lengthprijs op van € 88,50 per stuk.³¹

In dit voorbeeld wordt de operationele winst van de distributeur gerelateerd aan de omzet. Bij de toepassing van de TNMM voor een productievennootschap of een dienstverlenende entiteit ligt het voor de hand de operationele winst te relateren aan de kosten. Bij entiteiten waarbij de activa een betere indicator zijn voor de winstgevendheid zal de operationele winst worden gerelateerd aan de operationele activa. Het zal duidelijk zijn dat bij de laatste toepassing van de methode de problematiek van de waardering van de activa een extra complicerende factor is.

De reden waarom in de praktijk de TNMM vaak wordt gebruikt, ligt in het gegeven dat er bij vergelijking op operationeel niveau nog minder rekening hoeft te worden gehouden met verschillen in verslaggevingsregels. Classificatieverschillen met betrekking tot kosten leiden bij de vergelijkbaarheidsanalyse minder tot problemen. Tevens worden bij de analyse

³¹ De correctie is aangebracht tot de mediaan van de arm's-lengthrange. Dit is overeenkomstig het Nederlandse beleid indien de prijs buiten de range valt en er geen punt in de range valt aan te wijzen die het beste past bij de specifieke feiten en omstandigheden van de gecontroleerde transactie.

op het niveau van de nettowinst verschillen in de aard van de producten of diensten nog minder relevant dan bij de vergelijking op brutowinstniveau.

Eenzijdige analyse

Van de ondernemingen die zijn betrokken bij de concerntransactie zal vaak de gelieerde onderneming die de minst complexe functies uitoefent en die geen waardevolle immateriële goederen bezit, gekozen worden om te vergelijken met soortgelijke ondernemingen. Dit is de zogenaamde 'tested party'. De activiteiten van deze partij zijn vaak redelijk goed vergelijkbaar met die van soortgelijke ondernemingen die hun activiteiten op ongelieerde wijze uitoefenen.

Als voordeel van deze eenzijdige analyse wordt gezien dat deze slechts bij één van de bij de transactie betrokken partijen hoeft te worden uitgevoerd. Anderzijds wordt dit ook als een nadeel gezien, omdat bij een eenzijdige analyse geen rekening wordt gehouden met de totale winstgevendheid die met de transactie wordt beoogd. De voordelen van het in gelieerd verband samenwerken binnen een multinational vallen dan automatisch toe aan de partij met de meer complexe functies binnen de transactie. Overigens onderscheidt deze methode zich op dit punt niet van de resale-pricemethode en de cost-plusmethode.

De vergelijkbaarheid

Ook ten aanzien van de TNMM houdt vergelijkbaarheid in dat geen van de (mogelijke) verschillen tussen de vergeleken situaties materiële invloed heeft op de voorwaarden die met de methode worden onderzocht, of dat redelijk nauwkeurige correcties gemaakt kunnen worden om het effect van dergelijke verschillen teniet te doen. Net als bij andere methoden zal de betrouwbaarheid van noodzakelijke vergelijkbaarheidscorrecties de betrouwbaarheid van de analyse beïnvloeden.

Ook bij de TNMM zijn de vijf vergelijkbaarheidsfactoren, zoals beschreven in hoofdstuk 3, onverkort van toepassing. Niet alle factoren spelen bij de toepassing van de verschillende methoden een even belangrijke rol. Een sterk punt van de TNMM is dat operationele marges in vergelijking met prijzen minder gevoelig zijn voor verschillen met betrekking tot de goederen en diensten. De operationele marges zijn, in vergelijking met brutomarges, ook minder gevoelig voor beperkte functieverschillen. Verschillen in de functies tussen ondernemingen leiden vaak tot verschillen in exploitatiekosten. Bij een vergelijking op operationeel niveau komen zowel de hogere beloning als de hogere kosten in de nettowinst tot uitdrukking. Vergelijkbare ondernemingen kunnen daarom uiteenlopende brutowinstmarges hebben, maar toch nettowinsten behalen die bij een functionele analyse mogelijk vergelijkbaar kunnen zijn.

Overige aandachtspunten bij de vergelijkbaarheidsanalyse

Veel van de aandachtspunten die aan de orde zijn geweest bij de bespreking van de resale-price en de cost-plusmethode zijn ook van toepassing bij de TNMM. Op een aantal aspecten wil ik hier nader ingaan.

Een vergelijking op ondernemingsniveau voldoet niet aan de eisen van de OESO inzake vergelijkbaarheid indien één (of meer) van de ondernemingen meerdere functies uitoefent. Altijd dient gewerkt te worden met de operationele marges op een eng functioneel niveau. Dat geeft ook de mogelijkheid om terug te rekenen naar de prijzen van de transacties. Deze

voorwaarde kan in de praktijk zeer problematisch zijn, omdat openbare financiële informatie vaak geen inzicht geeft in de beloningen per functie bij ongelieerde ondernemingen.

Uit de analyse van de operationele kosten kan veel informatie worden verkregen over de functies en economische omstandigheden van de onderneming die van belang zijn bij de vergelijkbaarheidsanalyse en het zoeken naar betrouwbare 'comparables'. Het is daarbij goed om te kijken welke kosten iets zeggen over de functies, activa en risico's die een rol spelen bij de geanalyseerde transacties.

Het zal overigens vaak niet makkelijk zijn om de operationele kosten op een verantwoorde manier naar (groepen van) producten te herleiden. De toerekening is slechts eenvoudig als er één soort product wordt geproduceerd of geleverd. In de praktijk is dat doorgaans niet het geval.

In principe dient de vergelijking van de nettowinsten plaats te vinden vóór aftrek van interest en buitengewone baten en lasten. Maar de OESO-richtlijnen erkennen dat het bij de vergelijkbaarheidsanalyse van belang kan zijn deze kosten en baten wel in de analyse te betrekken. Dat speelt in ieder geval een rol indien deze kosten en baten, al dan niet indirect invloed hebben op de omvang van de operationele winst in het verleden of de toekomst. De kosten en baten na de operationele winst kunnen ook zeer zinvolle informatie geven over het functie- en risicoprofiel van de onderneming.³² Zo kan een hoge interestlast voortkomen uit het feit dat een onderneming haar klanten toestaat pas op een relatief laat moment de rekening te betalen. Dergelijke aspecten moeten in de functionele analyse meegewogen worden omdat een dergelijke omstandigheid invloed zal kunnen hebben op de prijs van de transactie.

Net als bij andere methoden zal bij de TNMM de mogelijkheid van noodzakelijke vergelijkbaarheidscorrecties de betrouwbaarheid van de analyse beïnvloeden. Hoewel aangevoerd zou kunnen worden dat de potentiële onnauwkeurigheden ondervangen kunnen worden door gebruik te maken van een arm's-lengthrange, zal het gebruik van een range niet altijd een oplossing zijn voor het gebrek aan kwaliteit van de 'comparables'. Een range maakt onbetrouwbaar vergelijkingsmateriaal nu eenmaal niet per definitie betrouwbaar. Omdat bij de TNMM echter vaak onzekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van de 'comparables' lijkt mij het gebruik van een arm's-lengthrange in combinatie met statistische methoden overigens wel aanbevelenswaardig om te komen tot 'comparables' die uiteindelijk wel geaccepteerd kunnen worden voor de vergelijking.

De Berry ratio

Tot slot nog aandacht voor een methode met een afwijkende benadering in vergelijking tot de TNMM. Het gaat hier om het gebruik van de zogenaamde 'Berry ratio'. In de richtlijnen wordt aandacht gegeven aan de toepassing ervan.³³ Hierbij wordt de vergelijking met ongelieerde ondernemingen gemaakt door de brutowinst af te zetten tegen de operationele kosten. Er bestaat grote terughoudendheid ten aanzien van de toepassing van deze methode omdat het niet altijd duidelijk is welke kosten nu precies meegenomen dienen te worden bij de bepaling

³² Par. 2.80-2.81 OESO-richtlijnen.

³³ Par. 2.100 OESO-richtlijnen.

van de operationele kosten. Dit kan leiden tot vergelijkbaarheidsproblemen. De methode wordt met name toegepast in situaties waarbij de onderneming als een tussenschakel opereert bij transacties tussen gelieerde ondernemingen en waarbij de operationele kosten een goede indicator zijn van de toegevoegde waarde van de uitgeoefende functies. In zo'n situatie doen zich sowieso problemen voor als de beloning zou worden gerelateerd aan de waarde van de in- of uitgaande transacties omdat deze in gelieerd verband plaatsvinden en wellicht niet als arm's length kunnen worden aangemerkt.

4.7 De profit-splitmethode

Onafhankelijke ondernemingen kunnen overeenkomen om de gezamenlijke winst die behaald wordt in een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een joint venture) op een bepaalde wijze te splitsen en onderling te verdelen. Dit principe vormt de basis van de acceptatie van de profit-splitmethode als verrekenprijsmethode. Ook bij gelieerde ondernemingen kunnen de transacties zodanig met elkaar verweven zijn, dat zij niet los van elkaar kunnen worden beoordeeld. Daarnaast kunnen bij bepaalde transacties partijen unieke intangibles bezitten, waarbij ze hun beloning gerelateerd willen zien aan de hand van de relatieve waarde van hun 'immateriële' inbreng. In dat geval kan de profit-splitmethode uitkomst bieden. De door de methode beoogde winstverdeling zal moeten benaderen hetgeen tussen onafhankelijke derden in een soortgelijke situatie zou zijn overeengekomen.

Bij de toepassing van de profit-splitmethode moet eerst de totale winst worden bepaald. Vervolgens moet die winst verdeeld worden over de gelieerde ondernemingen.

Er dient nog opgemerkt te worden dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen de profit-splitmethode gebaseerd op verwachte winsten en de profit-splitmethode gebaseerd op werkelijke winsten. Bij de eerste methode wordt op basis van de verwachtingen (budgetten) de winst (ex ante) verdeeld tussen de partijen. Daarna dient dan bijvoorbeeld een royaltyperscentage gekozen te worden die ervoor zorgt dat als de verwachtingen uitkomen de hantering van het percentage tot deze verwachte winstverdeling leidt. De werkelijke verdeling zal dan toch nog vaak anders zijn dan de gebudgetteerde verdeling. Bij de tweede methode wordt de werkelijke winst verdeeld op basis van een bepaalde verdeelsleutel. Dan wordt de splitsing niet tot stand gebracht door de bepaling van een onderlinge prijs.

De bijdrage van elke onderneming, die de basis is voor de verdeling van de winst bij deze methode, wordt feitelijk bepaald aan de hand van de uitgeoefende functies, inclusief de gelopen risico's en de gebruikte activa. Dat is hetzelfde uitgangspunt als bij de andere besproken methoden. Een sterk punt van de profit-splitmethode is dat beide partijen die bij de transactie zijn betrokken worden beoordeeld door middel van een tweezijdige (functionele) analyse. In de OESO-richtlijnen wordt erop gewezen dat dit aspect vooral belangrijk kan zijn bij de analyse van de relatieve bijdragen van de partijen met betrekking tot de immateriële activa.³⁴ Bij de verdeling van de gezamenlijke winst die ontstaat door synergie- en schaalvoordelen of andere voordelen als gevolg van optredende efficiency, lijkt een dergelijke tweezijdige analyse tot een betere uitkomst te leiden dan bij een eenzijdige

³⁴ Par. 2.109 OESO-richtlijnen.

analyse zoals de TNMM waarbij de focus meer gericht is op één van de betrokken partijen en het gevolg kan hebben dat de behaalde schaalvoordelen feitelijk bij slechts één van de partijen terechtkomen.

De profit-splitmethode en het arm's-lengthbeginsel

Het voordeel van de profit-splitmethode is dat deze methode in het algemeen niet direct afhankelijk is van in hoge mate vergelijkbare transacties en daarom kan worden toegepast in gevallen waarin er moeilijk of geen vergelijkbare transacties tussen onafhankelijke ondernemingen kunnen worden gevonden. De winst wordt verdeeld op basis van de analyse van de relatieve waarde van de inbreng van partijen. De vraag komt daarmee op of met behulp van deze methode verrekenprijzen nog wel worden getoetst aan het arm's-lengthbeginsel. In mijn visie kan deze vraag bevestigend worden beantwoord. Daarbij dienen wel zo veel mogelijk gegevens van onafhankelijke ondernemingen te worden gebruikt. Geanalyseerd dient te worden hoe ongelieerde partijen in soortgelijke omstandigheden hun winst plegen te verdelen. Het uiteindelijke doel is dat de relatieve economische waardetoevoeging in de verdeling van de winst tot uiting komt op een manier zoals ongelieerden dat in een dergelijke situatie ook gedaan zouden hebben. Als het bekend is dat soortgelijke ondernemingen bij een bepaalde transactie de winst verdelen op basis van een samengestelde allocatiesleutel van loonsom en aantal medewerkers, zal dit voor een gelieerd samenwerkingsverband ook uitgangspunt bij hun winstverdeling dienen te zijn.

De gekozen verdeling kan een vaste verhouding zijn of afhankelijk worden gemaakt van variabele gegevens, zoals bijvoorbeeld de relatieve omvang van de daadwerkelijk gemaakte marketingkosten. Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden zal gezocht moeten worden naar een allocatiesleutel die recht doet aan de relatieve toegevoegde waarde van de inbreng van partijen. Bij de keuze van de verdeelsleutel dient wel een grote mate van voorzichtigheid te worden betracht. Zo zal een sleutel die gebaseerd is op de gemaakte kosten van beide partijen lang niet alles zeggen over de waarde van hetgeen wordt ingebracht in het samenwerkingsverband. Bij de ontwikkeling van unieke intangibles zeggen de gemaakte kosten weinig over de toegevoegde waarde.

Een verdeling van de winst op basis van gemaakte kosten levert sowieso problemen op als op voorhand niet duidelijk meegewogen wordt hoe de relatie is tussen de periode waarin de kosten worden gemaakt en de periode waarin de opbrengsten worden gerealiseerd. Bij complexe transacties ligt het moment van kosten en het moment van opbrengsten vaak ver uit elkaar.

Hoewel de profit-splitmethode in beginsel kan leiden tot een zakelijke prijs kunnen er natuurlijk ook een aantal nadelen van het gebruik van deze methode worden aangewezen.³⁵

- De externe marktgegevens die gebruikt worden bij de beoordeling zijn minder nauw gerelateerd aan de transacties als zodanig.
- Het is soms moeilijk om voldoende informatie te verkrijgen van de buitenlandse gelieerde partij die deelneemt in de transactie.
- Boekhoudkundige verschillen en valutaverschillen kunnen het bepalen van de gezamenlijke winst en kosten bemoeilijken.

³⁵ Par. 2.114 OESO-richtlijnen.

- Het kan moeilijk zijn om de gezamenlijke inkomsten en kosten te bepalen van alle gelieerde ondernemingen die deelnemen aan de concerntransacties.
- Als de winst verdeeld wordt op basis van een bepaalde allocatiesleutel maar de verschillende (fiscale) winstbepalingsstelsels niet op elkaar aansluiten, kan dit leiden tot complexe uitvoeringsproblemen.³⁶

De te splitsen winst

In het algemeen wordt de te splitsen winst bepaald op het niveau van de operationele winst. Dit garandeert volgens de OESO-richtlijnen dat zowel inkomsten als kosten met betrekking tot de uitgeoefende transacties op consistente wijze worden gealloceerd aan de gelieerde ondernemingen. Het nadeel van het toepassen van de profit-splitmethode op het niveau van de operationele winst is dat het moeilijk kan zijn de exploitatiekosten die in verband staan met de transacties vast te stellen, omdat het moeilijk is de kosten te verdelen tussen de geanalyseerde transacties en de overige activiteiten van de ondernemingen. Een onderneming zal namelijk doorgaans meer doen dan alleen de geanalyseerde activiteiten. In de richtlijnen wordt de mogelijkheid opengelaten de winstsplitsing op het brutowinstniveau te laten plaatsvinden.³⁷ Bij de laatste methode worden de 'eigen' operationele kosten van de toegerekende gesplitste brutowinst afgetrokken en doen deze niet mee in de 'split'.

Contributieanalyse of restwinstanalyse³⁸

Contributieanalyse is één van de in de OESO-richtlijnen genoemde methoden om de winst te splitsen. Bij toepassing van de contributieanalyse wordt de gezamenlijke winst met betrekking tot een gezamenlijk uitgeoefende transactie tussen de gelieerde ondernemingen verdeeld op basis van de relatieve waarde van de uitgeoefende functies. Hierbij moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van externe gegevens waaruit blijkt hoe derden deze winst verdeeld zouden hebben. In het algemeen wordt voor de te splitsen winst de operationele winst als uitgangspunt genomen.

De andere genoemde methode is de restwinstanalyse.³⁹ Bij een restwinstanalyse wordt de gezamenlijke winst van de samenwerkende gelieerde partijen met betrekking tot een transactie in twee stappen geanalyseerd en verdeeld. In de eerste stap wordt aan elke gelieerde onderneming voldoende winst toegerekend om deze partij een passende beloning te verschaffen voor de door haar uitgeoefende routinematige functies. Deze beloning zal volgens de OESO-richtlijnen gewoonlijk worden vastgesteld aan de hand van de beloning die door onafhankelijke ondernemingen met soortgelijke routinematige activiteiten zou zijn behaald. Na de toerekening van de beloning aan de routinefuncties blijft over de winst of verlies die verdeeld moet worden in verband met de bijdrage van de partijen aan de complexere functies. Deze winst wordt de restwinst ('residual') genoemd die in de tweede stap wordt verdeeld. Uitgangspunt hierbij is de relatieve waarde van ieders bijdrage.

³⁶ Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van de vorming van een voorziening die volgens het jaarrekeningrecht is toegestaan, maar fiscaal in het ene land wel en in het andere land niet wordt geaccepteerd.

³⁷ Par. 2.131 OESO-richtlijnen.

³⁸ Par. 2.118-2.123 OESO-richtlijnen.

³⁹ Zie: OECD, *The Taxation of Global Trading of Financial Instruments*, 1998, blz. 44; Hierin worden de opinies van voor- en tegenstanders van de toepassing van de residual profit-splitmethode op global-tradingoperaties beschreven zonder daarbij een keuze te maken.

Winstsplitsing op basis van prognoses

Als gelieerde ondernemingen de profit-splitmethode toepassen om verrekenprijzen vast te stellen, dan zullen de op deze wijze vastgestelde voorwaarden op de geraamde winsten worden gebaseerd. Het is voor de belastingplichtige onmogelijk op het moment waarop de voorwaarden worden vastgesteld te weten hoe groot de winst van de activiteit daadwerkelijk zal zijn. In de OESO-richtlijnen wordt erop gewezen dat belastingdiensten hiermee ook rekening dienen te houden bij het beoordelen van de methode.⁴⁰ Ook hier geldt weer dat het gebruikmaken van 'hindsight' niet is toegestaan. Beoordeeld moet worden of de wijze waarop de voorwaarden tussen partijen bij aanvang zijn vastgesteld, overeenkomt met wat ongelieerden in dergelijke omstandigheden zouden hebben gedaan, rekening houdend met de feiten en omstandigheden die op dat moment bekend waren.

Natuurlijk moet wel worden nagegaan of de werkelijke verdeling van de winst gebeurt op basis van de bij aanvang gekozen uitgangspunten.

40 Par. 2.128 OESO-richtlijnen.